

1502706-02.2021.8.26.0597

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502706-02.2021.8.26.0597 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502706-02.2021.8.26.0597

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2194996/2021 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 13663130 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 94/21/901 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO, 2194996 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE LEAL GUSMÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

PEDRO HENRIQUE LEAL GUSMÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 08h00, na rua Miguel Jambre, s/n (ao lado do numeral 275), Jardim Ouro Preto, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 72 (setenta e duas) porções de Maconha pesando 369,8g (trezentos e sessenta e nove gramas e oito decigramas), substância entorpecente capaz de determinar a dependência física e psíquica.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, policiais civis efetuavam o cumprimento de mandados de busca domiciliar em residências próximas ao local dos fatos (autos nº 1502485-19.2021.8.26.0597) quando notaram uma movimentação estranha na casa situada ao lado do numeral 275. Assim que o indivíduo que se encontrava no interior deste imóvel – posteriormente identificado como o réu – notou a presença da viatura, rapidamente se evadiu a bordo de uma bicicleta, deixando-o com a porta aberta. Diante disso e do fato de que o local exalava um forte odor de drogas, os policiais adentraram o local e nele localizaram 72 (setenta e duas) porções de Maconha, um simulacro de arma de fogo, duas balanças de precisão, uma faca, três aparelhos celulares, R\$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro e a carteira de identidade e de trabalho do acusado.

A denúncia foi recebida em 14 de outubro de 2021 (fls. 60/61), o réu foi citado (fls. 87) e apresentou resposta à acusação (fls. 90/91).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como foram ouvidas cinco testemunhas arroladas pela Defesa, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls. 159/162).

A Defesa do acusado requereu, preliminarmente, a decretação da ilicitude da prova colhida, por desrespeito à regra da inviolabilidade do domicílio. No mérito, pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Em cenário de condenação, a Defesa requereu penas mínimas, além da aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/068. Por fim, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e recurso em liberdade (fls. 175/184).

É o relatório.

DECIDO.

De proêmio, mister afastar a preliminar de nulidade processual em razão da ilicitude da prova, sob o fundamento de mácula à garantia da inviolabilidade do domicílio.

Os agentes de segurança relataram que estavam próximo ao local de apreensão de drogas em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão. No local indicado no mandado de busca, nada de ilícito foi apreendido, entretanto, houve suspeita fundada sobre a existência de armazenamento de drogas em endereço próximo, culminando com a devassa do domicílio do acusado.

Ao contrário do que quer fazer crer a defesa, houve diligência prévia que levou os policiais até o local dos fatos. E embora o endereço do réu não fosse o destino inicial da diligência, os agentes de segurança ali estavam em razão de ordem legal, não havendo que se falar em mera intuição.

Além disso, aliado ao mandado de busca e apreensão indicando local próximo como sendo de ocorrência de ilícitos, o fato de que foi flagrado uma pessoa fugir do imóvel em uma bicicleta, quando da aproximação dos policiais, deixando a porta e o portão abertos, bem como sentido pelos policiais forte odor de Maconha vindo do imóvel do réu, devem ser considerados, no caso concreto, como suspeita fundada da ocorrência de crime permanente, cuja ocorrência de protraí no tempo por querer do agente, justificando a devassa domiciliar em razão da exceção de inviolabilidade prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, dispensando-se mandado de busca domiciliar específico para o endereço do acusado.

Neste sentido recentemente decidiu o C. STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO PARCIAL DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Parte do objeto deste writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do HC 199.091/RJ. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de pedido anterior. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo

Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 5. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 213852 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022)

Em situação semelhante, igualmente já decidiu o C. STJ:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESCOBERTA FORTUITA DOS ENTORPECENTES OCORRIDA NO CONTEXTO DE BUSCA POR ARMA DE FOGO UTILIZADA EM ROUBO OCORRIDO HORAS ANTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE PELA VÍTIMA DO ROUBO. FUGA DO PACIENTE PELA JANELA DA RESIDÊNCIA, EM DIREÇÃO A MATA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL." (HC n. 614.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020.)

No mérito, a pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelas imagens fotográficas (fls. 12/18), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 25/27), conclusivo por se tratar de Maconha, pelos laudos periciais (fls. 28/29 e 30/34) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também foi devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos.

Os policiais civis André e Marco Aurélio, na fase policial, disseram que durante a Operação Narco Brasil, realizaram o cumprimento do mandado de busca domiciliar expedido nos autos do processo 1502485-19.2021.8.26.0597, nas residências localizadas na rua Miguem Jambre nº230 e nº252, cujas diligências restaram infrutíferas. Notaram uma movimentação estranha próximo ao local dos fatos, tendo em vista que enquanto estavam procedendo às buscas nas residências de numeral 230 e 252, um indivíduo que estava na residência ao lado do numeral 275 deixou o local de bicicleta rapidamente, abandonando o imóvel com a porta aberta. Diante da suspeita, foram até a frente da casa e sentiram um forte odor de Maconha vindo do interior do imóvel. Suspeitando de que no local estivesse sendo utilizado para guarda de drogas, resolveram revistar o imóvel, o qual estava sem moradores e com a porta aberta. Dentro do imóvel, encontraram 72 (setenta e duas) "trouxinhas" de erva esverdeada aparentando ser Maconha, um simulacro de arma de fogo, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (uma) faca, 03 (três) aparelhos celulares, o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e ainda os documentos apreendidos, pertencentes ao acusado, Pedro Henrique Leal Gusmão. Apesar das diligências, Pedro Henrique não foi localizado. A pessoa que abandonou o imóvel na bicicleta antes das buscas era, sem qualquer sombra de dúvida, Pedro Henrique Leal Gusmão. Por fim, informaram que o réu não era o alvo das buscas do mandado de busca domiciliar (fls. 50 e 51).

A testemunha Marco, em Juízo, ratificou o relato anterior, acrescentando que a região onde estavam é conhecida pela ocorrência de droga e seus outros colegas de profissão conheciam o réu também. Esclareceu que conseguiram entrar no imóvel pois a porta foi deixada aberta pelo indivíduo que fugiu. Ressaltou que não conhecia o réu anteriormente e que não tem condições de reconhecer o réu como sendo a pessoa que fugiu do imóvel. Disse que o mandado que estavam cumprindo não era concernente ao imóvel no qual acharam as drogas, mas foram informados por outros policiais de que um rapaz havia deixado o local, em atitude suspeita. Diante das suspeitas e do odor típico, entraram no imóvel e constataram que não havia mais ninguém no local. Por fim, resumiu que estava em mandado de buscas sobre outro local, porém o local da ocorrência abordada levantava bastantes suspeitas, visto que a moradia estava localizada em ponto conhecido pelo tráfico de drogas, além de haver uma pessoa evadindo-se e o local estar exalando odor de drogas. Continuou que a porta estava aberta, não havia moradores, e lá foram encontrados entorpecentes, o simulacro, a faca, os documentos e o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) (v. mídia).

A testemunha Andre, em Juízo, ratificou o relato anterior, esclarecendo que o mandado que estavam cumprindo era relativo à residência vizinha, e não tinha relação com a casa de Pedro. Esclareceu que a casa fica perto da praça do pedregal, onde ocorre tráfico com frequência, e que estava exalando um forte odor de Maconha. O depoente disse que foi ele quem viu o réu sair da residência e deixando a porta e o portão abertos. Acrescentou que não teve contato anterior ou posterior com o réu. Disse que os vizinhos confirmaram que Pedro estava morando ali. Afirmou que a casa estava vazia, e foi possível constatar isso antes mesmo de entrar, pois chamaram pelos moradores, e não havia ninguém. Quanto aos objetos apreendidos, disse que estavam espalhados pelos cômodos da casa (v. mídia).

Suellen, testemunha arrolada pela Defesa, ouvida em Juízo, disse que é sogra do réu. Morava próximo ao réu (um quarteirão), na época dos fatos. Disse que Pedro morava sozinho e estava trabalhando na data dos fatos. Afirmou que o réu não trafica drogas e que trabalha com o padraço dele (v. mídia).

Danila, testemunha arrolada pela Defesa, ouvida em Juízo, disse que é tia da esposa do réu e morava próxima dele. Afirmou que estava dormindo, no dia dos fatos, quando ouviu sua irmã falando que a polícia estava na casa do Pedro. Quando acordou, os policiais não estavam mais na residência, estavam em uma pracinha lá próximo. Disse que conversou com os policiais, e eles perguntaram a ela se havia drogas em sua residência, mas ela disse que não (v. mídia).

Ingrid, testemunha arrolada pela Defesa, ouvida em Juízo, disse que é tia da namorada do réu e mora no mesmo local que a testemunha Danila (irmãs). Disse que viu quando os policiais entraram na casa do Pedro, mas não viu os policiais saírem com nada em mãos. Afirmou que não havia ninguém na casa, e que Pedro estava trabalhando no dia. Ouviu comentários de que o réu era usuário de Maconha, mas nunca viu nada (v. mídia).

Fernando, testemunha arrolada pela Defesa, ouvido em Juízo, disse que teve relacionamento com a mãe do réu, há um ano e seis meses, e que trabalhava com ele nesse período. Disse que o réu não trabalha mais com ele há pelo menos um ano, mas o indicava para outros serviços. Disse que mora próximo da casa da mãe do acusado, e que a visita com frequência. Disse que soube da internação do réu na Fundação Casa, pois já estava com a mãe dele, mas não soube informar o motivo (v. mídia).

Ketherin, testemunha arrolada pela Defesa, disse que é companheira do réu há dois anos. Disse que tinha dormido um dia antes, na casa do réu, e no outro dia ele a levou embora e foi trabalhar com Fernando, sendo que Fernando tinha um relacionamento com a mãe do Pedro. Asseverou que seus documentos estavam na casa do réu. Aduziu que o réu fazia uso de Maconha, todas as noites, quando tinha dinheiro. Disse que não comprava mais do que 15g (quinze gramas), e comprava poucas porções. Arrematou dizendo que a residência do réu fica próxima à Praça do Pedregal. (v. mídia).

O réu, ao ser interrogado na fase policial, negou a prática delitiva, alegando que é usuário de Maconha e Cocaína. Quanto aos fatos, as drogas e petrechos apreendidos em sua casa pertencem ao próprio interrogando, parte delas para seu próprio consumo, outra parte para comércio. Mora sozinho no imóvel e sua namorada, Kathrein, pernoita lá de vez em quando, porém ela não tem qualquer envolvimento com as drogas e objetos localizados em sua casa. No dia dos fatos, saiu de casa por volta de 06H00, a pé e não chegou a ver policiais civis em sua rua, ou seja, nega que tenha se evadido de casa ao perceber que havia uma ação da Polícia Civil ali por perto. Deixou o portão da casa apenas "encostado" e a porta da cozinha aberta, como de costume. Não vende porções de Maconha de tamanho "padrão", ou seja, dependendo da quantidade que o usuário deseja comprar, o interrogando corta um pedaço da droga e cobra o preço de acordo com o peso, que era aferido nas balanças apreendidas. Atualmente faz "bicos" de pintor e ganha R\$ 70,00 (setenta reais) por diária. Desde a maioridade, nunca foi preso. Já esteve internado na Fundação CASA por três vezes, duas por tráfico de drogas e uma por roubo (fls. 35).

Em Juízo, disse que não estava em casa e que tinha saído cedo para trabalhar, como ajudante de pedreiro do Zé Carlos, indicado por Fernando. Não reconheceu os objetos encontradas da casa como sendo seus, exceto pelo documento e por dois celulares. Disse que assumiu a autoria do delito porque estava sendo ameaçado pelos policiais.

Já ficou internando na Fundação Casa por tráfico de drogas e por roubo. Ficou internando por períodos de 08 (oito) meses, 07 (sete) meses e 01 (um) ano e 03 (três meses). Asseverou que namora Katherin desde agosto de 2020 e que os documentos dela também foram apreendidos na ocasião. Assumiu que usava Maconha para dormir, pela noite e que levava a droga consigo quando saía. Disse que já foi abordado pela testemunha André, em 2018, e em 2020, e neste último episódio André pediu informações a ele, por meio de ameaças. Verbalizou que na data próxima de seu interrogatório, na fase policial, foi coibido por André a confessar a autoria dos delitos. Asseverou que foi dar seu depoimento, mas estava muito assustado e levou uma advogada, e mesmo na frente dela assumiu que vendia droga. Disse que respondeu à duas perguntas em seu interrogatório, mas não leu nada, apenas assinou (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida e que se destinaria à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais civis, estavam cumprindo um mandado de busca, mas por conta da suspeita levantada em relação à casa em voga, decidiram averiguar o local.

Isso porque, além de o réu ter sido flagrado se evadindo do local, em uma bicicleta, deixando a porta e o portão abertos, os policiais sentiram forte odor de Maconha vindo do local, ademais, lá dentro encontraram 72 (setenta e duas) "trouxinhas" de Maconha, um simulacro de arma de fogo, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) faca, 03 (três) aparelhos celulares, o valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) e ainda os documentos do acusado.

O réu, por sua vez, negou a prática delitativa, alegando que é usuário de Maconha e Cocaína e que parte das drogas e petrechos apreendidos era destinada ao seu consumo próprio, e outra parte era para comercialização. Alegou não vender porções de Maconha de tamanho "padrão", fracionando pedaços da droga de acordo com o peso, por isso faz uso da balança de precisão. Em Juízo, mudou em partes sua versão, dizendo que não reconheceu os objetos apreendidos como sendo os seus, exceto pelo documento de identificação e por dois celulares apreendidos. Disse que sua confissão na fase policial foi motivada por coerção da testemunha André, porém não trouxe elementos de prova que pudessem respaldar sua alegação.

O réu disse ainda que não estava no local, e que estava trabalhando, entretanto, em solo policial admitiu a propriedade da droga, fazendo-o na presença de sua advogada. Por outro lado, admite o réu ser morador do local e o fato de estar ausente no dia dos fatos, independentemente do motivo, diante do quadro probatório, não afasta sua conduta típica de manter em depósito substâncias ilícitas.

Pontue-se que os relatos das testemunhas de defesa afirmando que o acusado não estava na residência, fato também ratificado pelos policiais civis, por estar trabalhando, não é suficiente para afastar a convicção judicial, diante do quadro fático representado pelas fontes de provas sobre o exercício da traficância.

Além de restar incontestado que o acusado residia no local onde foram encontradas as drogas, inclusive por relatos feitos por vizinhos do acusado aos policiais civis, houve apreensão de seus documentos pessoais e petrechos utilizados para venda de drogas, conjunto fático que confirma a acusação posta na exordial acusatória.

Observe-se que a credibilidade dos depoimentos dos policiais ainda vem corroborada pela prova documental e pericial já citadas, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que tivessem a intenção de prejudicar o acusado.

Ademais, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as

demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de policiais ou de guardas municipais para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada." (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Coeso testemunho dos policiais militares - Validade - Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório - Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Tráfico caracterizado - Condenação mantida - PENA - redutor no patamar máximo - necessidade - Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto - Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 - Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves - d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP - Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 - Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira - d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROVA ORAL INCRIMINADORA - A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES - O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENHIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA PENAL INALTERADA - REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 - Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib - d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de

ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16a Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9a Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200). Assim, considerando a significativa quantidade de droga encontrada na residência do réu, superior ao que normalmente é encontrado com meros usuários, bem como a forma como estavam acondicionadas, e que o réu foi flagrado fugindo do local, em atitude muito suspeita, conclui-se pelo exercício da mercancia de entorpecentes. A acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base do réu no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, de rigor ainda o reconhecimento da atenuante da confissão e da menoridade relativa do agente. No entanto, estas circunstâncias não tem o poder de fazer com que a pena seja reduzida abaixo do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, inicialmente observo que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente a fração a ser aplicada, deve observar as diretrizes previstas no art. 42 da mesma lei, que impõe seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Neste sentido:

"O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada." (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Assim, levando em conta que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, também não havendo provas de que integre organização criminosa, reduzo as penas acima indicadas em 2/3 (dois terços), totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos",

constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional. ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma suprallegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito "erga omnes", cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao

juiz sentenciante “o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo”. Ponderou também que “a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero”.

Assim sendo, analisando o caso concreto, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime.

Destaco que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente são, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu PEDRO HENRIQUE LEAL GUSMÃO, qualificado nos autos, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, “caput”, c.c. § 4º, da Lei 11.343/06.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, por força da decisão proferida pelo STF no HC nº 596.603 SP (2020/0170612-1), podendo recorrer em liberdade diante da primariedade.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Expeça-se alvará de soltura de clausulado.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 15 de agosto de 2022

Angel Tomas Castroviejo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA